

1500282-81.2022.8.26.0037

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Humberto Isaías Gonçalves Rios

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉU CLAUDIOMAR QUE GUARDAVA CERCA DE 7kg DE COCAÍNA - PALAVRAS DOS POLICIAIS CIVIS EM SINTONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO MINISTERIAL REQUERENDO A CONDENAÇÃO DO RÉU DANIEL PELO TRÁFICO E A CONDENAÇÃO DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

2ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses nº 1998, Araraquara - SP - cep 14801-425

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500282-81.2022.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500282-81.2022.8.26.0037

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

FERNANDA GISELDA BATISTA ANSELMO e outros

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Humberto Isaías Gonçalves Rios

Vistos.

WILLIAN ANSELMO PEREIRA, GIONATHAN EDUARDO MAURO SACHS e FERNANDA GISELDA BATISTA ANSELMO, estão sendo processados pela Justiça Pública, por incursos nas penas dos artigos 33, "caput" e 35, ambos da Lei n. 11.343/06 e artigo 12, da Lei n. 10.826/03, todos cumulados com artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal e na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, como narra a peça inicial, aos 02 de fevereiro de 2022, por volta das 06:10 horas, na Rua Dorival Arlindo Falcone, n. 22, bairro Jardim Maria Luiza, nesta cidade, previamente ajustados e agindo com unidade de propósitos e desígnios, guardavam e tinham em depósito, para fins de mercancia, 08 (oito) porções de maconha (peso líquido de 92,20 gramas), 07 (sete) porções de cocaína, na forma de crack (peso líquido de 0,92 gramas), 01 (um) microtubo contendo cocaína (peso líquido de 0,58 gramas), 54 (cinquenta e quatro) unidades de segmentos de papel do tipo "picote", contendo Metanfetamina, 2C-E (4-ETIL-2,5- DIMETOXIFENILETILAMINA) e 2C-B (4-BROMO-2,5- DIMETOXIFENILETILAMINA), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia, ainda, que, a partir de data incerta, mas até 02 de fevereiro de

2022, no lugar acima descrito, os referidos denunciados, também agindo previamente ajustados e com identidade de propósitos entre si, estariam associados para o mesmo fim de praticar tráfico de drogas.

FERNANDA GISELDA BATISTA ANSELMO foi também denunciada como incurso no artigo 33, § 1º, inciso III, da Lei n. 11.343/06 porque, além de ter concorrido para a guarda, preparação e depósito dos entorpecentes, consentiu que Willian, seu filho, utilizasse o imóvel para a preparação e guarda das drogas.

Por fim, consta da mesma denúncia que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, os referidos denunciados, também agindo previamente ajustados e com unidade de propósitos e desígnios, no interior de sua residência, possuíam e mantinham sob sua guarda 06 (seis) munições de uso permitido, da marca CBC, calibre .32-20 (.32 Winchester), em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por decisão de fls. 83/86 houve a conversão da prisão em flagrante dos acusados em preventiva.

Adotado o rito ordinário, a denúncia foi recebida (fls. 314/317), os acusados foram citados (fls. 354/355, 356/357 e 358/359) e ofereceram resposta à acusação (fls. 336/353 e 363/365).

Afastada as respostas iniciais apresentadas, foi deferida a assistência judiciária gratuita aos réus e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 375/376).

À fls. 419/420 restou mantida a custódia preventiva dos acusados.

Em audiência por videoconferência, foi colhida a prova testemunhal, sendo, ao final, interrogados os réus (fls. 443/453 e mídia).

Encerando-se o ato, as partes apresentaram alegações finais, pronunciando-se o Ministério Público pela condenação do réu Willian pelo crime de tráfico de drogas e guarda de munições, nos termos da denúncia, e absolvição dos demais réus com consequente reconhecimento da inexistência de associação delitiva (fls. 444/449).

A Dra. Defensora Pública requereu a absolvição dos acusados Willian e Gionathan, por insuficiência de provas e de autoria (Gionathan) ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 (ambos) ou, sucessivamente, para aquela prevista no art. 33, §3º, da mesma lei (Willian). Em caso de condenação, postulou pela observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, do art. 42, da Lei n. 11.343/06 e Súmula 444/STJ, pleiteando o afastamento da causa de aumento imposta e que seja fixado regime aberto para o cumprimento da pena, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em favor do corréu Gionathan (fls. 449/452).

A Defesa da corré Fernanda também requereu a absolvição da acusada por insuficiência de provas, pleiteando a observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, em caso de condenação, com fixação da pena no patamar mínimo e regime menos gravoso (fls. 454/462).

É, em síntese, o relatório.

Decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou incontestada pelo boletim de ocorrência de fls. 11/14, autos de exibição e apreensão de fls. 24/25, bem como pelas fotografias de fls. 35/37, laudos periciais (fls. 135/137, 138/140, 141/143, 144/145, 146/148, 149/151, 152/154, 155/157, 158/159, 160/162, 163/165, 166/169 e 170/172) e pela prova oral colhida nos autos. É evidente, portanto, a existência material dos crimes de tráfico e de guarda irregular de munições.

A) Com relação ao réu WILLIAN:

A prova oral coligida aos autos evidenciou que o acusado Willian guardava e mantinha em depósito substâncias entorpecentes, para fins de comércio, bem como mantinha a guarda irregular de munições de arma de fogo.

O policial civil Higor Procopio disse que em investigação de um crime de roubo em um posto de combustível, obtiveram a ordem de adentrar na residência de William e Fernanda, para buscar objetos, vestimentas e armas eventualmente utilizadas no dia do roubo, na qual encontraram produtos também de um outro roubo perpetrado no dia anterior no mesmo estabelecimento, bem como flagraram simulacros de arma de fogo, munições e entorpecentes. Afirmou que logo que ingressaram na residência, os corréus William e Gionathan estavam dormindo na sala, e Fernanda se encontrava no

quarto. Disse que a sala estava desorganizada com roupas e colchão jogados, onde encontraram dois simulacros de arma, vestimentas usadas nos roubos, uma balança de precisão, 4 porções de maconha, 1 microtubo de cocaína, 6 cartuchos de munição calibre .32 e 755 microtubos vazios para embalo de cocaína, tudo de fácil visibilidade. No banheiro encontraram outras vestimentas relacionadas ao roubo, assim como 2 porções maiores de maconha abaixo de um botijão de gás. Na cozinha encontraram, em cima da geladeira, 2 fracos semelhantes a "lança-perfume" e, dentro de um recipiente de arroz, havia 1 embalagem pequena de fermento em pó, com 7 pedras semelhantes a "crack" e 54 pontos de "LCD". No fundo da residência, afirmou que havia uma edícula de uso comum, onde foi localizada uma mesa contendo porção esfarelada de substância semelhante a maconha, além de material de embalo (papel-filme e saco plástico), e facas com resquícios da mesma substância. Assim, diante dos fatos, foi decidido pela prisão em flagrante dos réus. Indagado, disse que na residência moravam a corré Fernanda e o corréu Willian. Todos negaram os fatos, tendo o Willian confidenciado que traficava por sobrevivência, sendo este conhecido pela polícia. Quanto às munições, afirma que nada alegaram, e que apesar de questionados, não colaboraram, não sendo localizada a arma de fogo correspondente. No quarto dos corréus Willian e Fernanda nada foi encontrado. Relata ainda que o corréu William negou que sua genitora, ora corré Fernanda, soubesse ou praticasse os delitos imputados, com quem foi apreendido um aparelho celular e apresentava nervosismo, quando dos entorpecentes encontrados na residência, não sendo localizado nada na posse direta da mesma. Opinou que não teria como a corré Fernanda desconhecer sobre os delitos (fls. 443/453 - mídia: 40seg). No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil, Marco Antonio de Toledo Francisco, retificando quanto a todos estarem tranquilos por ocasião da abordagem; acrescentando sobre a inexistência de investigação de eventuais delitos anteriores com relação à corré Fernanda (fls. 443/453 - mídia: 18min).

Interrogado, o corréu Willian admitiu sobre a traficância e uso de todos os entorpecentes encontrados, assim como a titularidade das munições apreendidas, e participação com terceiro em um dos roubos investigados, negando qualquer envolvimento dos demais corréus. Afirma que sua genitora tinha conhecimento dos entorpecentes, mas tinha receio em razão de sua agressividade; que ela não participava da sua conduta criminosa, tampouco sabia os locais onde ele guardava os entorpecentes. Esclareceu que após longo tempo, o corréu Gionathan compareceu em sua residência por volta das 21 horas do dia anterior; que não se encontravam costumeiramente (fls. 443/453 - mídia: 1h05min).

Percebe-se, de início, que esta prova oral coligida aos autos, por si só, foi apta a incriminar o réu Willian, mormente porque respaldada pela apreensão das drogas e munições admitidas.

Os depoimentos dos policiais foram coerentes e harmônicos, nos quais, inclusive, foram categóricos em elencar as substâncias apreendidas, esclarecendo nos depoimentos prestados acerca da Menta-fetamina e Dimetoxifeniletamina corresponder ao "LSD" e "Lança-perfume" apreendidos. Reserva alguma há de se impor, "in casu", ao depoimento dos policiais, como reiteradamente decidido, "os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade das testemunhas em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve para informar o convencimento do julgador" RT, vol. 616/287; no mesmo sentido, RT, vols. 433/386; 445/384; 479/382; 634/276; RJTJESP, ed. LEX, vols. 95/400; 107/457 e 189/328; JUTACrim, vols. 8/24; 67/369; 76/331).

Ademais, nos termos do art. 202 do CPP, "toda pessoa poderá ser testemunha" e a defesa não trouxe qualquer motivo concreto capaz de afastar sua credibilidade, inexistindo razão para crer que os policiais estejam em busca de incriminar falsamente pessoa inocente. Por isso, seus relatos são de grande valia e constituem prova válida para formar a convicção acerca dos fatos apurados neste processo.

Sobre a palavra dos policiais, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉU CLAUDIOMAR QUE GUARDAVA CERCA DE 7kg DE COCAÍNA - PALAVRAS DOS POLICIAIS CIVIS EM SINTONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO

MINISTERIAL REQUERENDO A CONDENAÇÃO DO RÉU DANIEL PELO TRÁFICO E A CONDENAÇÃO DE AMBOS OS RÉUS PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONFISSÃO INFORMAL DE CLAUDIOMAR PARA OS POLICIAIS CIVIS CONFIRMANDO A PARTICIPAÇÃO DE DANIEL – Conjunto probatório que aponta que Daniel era quem movimentava a droga e tinha experiência no comércio clandestino, sendo Claudiomar responsável apenas por armazenar o entorpecente, tanto que o último tinha ocupação lícita – REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAÇÃO DE DANIEL – NECESSIDADE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – NÃO COMPROVADA A ESTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO ENTRE DANIEL E CLAUDIOMAR – ABSOLVIÇÃO- NECESSIDADE – RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL.” (Apelação Criminal 1500276-87.2019.8.26.0196; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 1ª Vara Criminal; j. 09/06/2020)

A versão do agente da autoridade somente pode ser desconsiderada se elidida por outro elemento de convicção trazido aos autos, o que não ocorreu.

Ainda, somada à confissão do corréu Willian nas duas fases em que ouvido, as circunstâncias, efetivamente, demonstram, que, além da guarda das munições, as substâncias entorpecentes apreendidas, assim como o material para embalagem, eram destinadas ao comércio; para a configuração do tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja flagrado vendendo a droga, mas basta a análise das condições em que o crime foi cometido e essas demonstram que as substâncias entorpecentes apreendidas eram destinadas à venda. Não se trata apenas de presunção, pois a própria dinâmica dos fatos exposta pelos agentes públicos durante a instrução criminal corrobora o acondicionamento em plástico, papel-filme e microtubos individuais, em parte já prontos para o comércio. A quantidade e, em especial, a variedade e forma de embalagem dos entorpecentes – fora as munições (atestadas pelo laudo pericial de fls. 149/151), convence de sua destinação mercantil e impede o desclassificar para os delitos do art. 33, § 3º, e/ou do art. 28, da Lei de Tóxicos vigente, não sendo o caso de se reconhecer a inconstitucionalidade desse disposto. Acrescente-se, ainda, que o fato de dizer-se usuário não implica que não possa também traficar. É verdade corrente que, para sustentar seu vício, o usuário sem efetiva atividade laborativa se dedica a venda de droga a terceiros. Sobre o tema, confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de DROGAS – Recurso defensivo – Pleito de absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade delitiva e autoria sobejamente demonstradas nos autos – Circunstâncias da prisão que comprovam que o acusado se dedicava à mercancia ilícita – Validade dos depoimentos dos agentes públicos – Ademais, quantidade de entorpecentes e circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação ao consumo de terceiros – Desclassificação da imputação de tráfico para uso – Descabimento – A condição de mero usuário não exclui, por si só, a prática da mercancia ilícita – Circunstâncias em que se deu a prisão do recorrente, somadas à apreensão de considerável quantidade de entorpecente, que dão a certeza que a droga se destinava à mercancia ilícita – Condenação mantida – Pretendida aplicação da causa de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 – Desacolhimento – A despeito da primariedade do agente, a quantidade de droga e dinheiro apreendidos em poder do acusado, além de balança de precisão, demonstram a dedicação dele à atividade criminosa e impedem, por consequência, a aplicação do aludido redutor – Recurso desprovido. Recurso ministerial – Pretendida elevação da pena-base – Acolhimento – Quantidade considerável de entorpecente apreendido em poder do acusado – Preponderância do art. 42, da citada lei, sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal – Fixação de regime inicial fechado – Necessidade – Gravidade concreta do delito cometido pelo acusado que determina a fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal – Crime equiparado a hediondo, que reclama resposta penal mais rigorosa – Recurso provido.” (Apelação Criminal 1501329-65.2019.8.26.0047; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Assis - 1ª Vara Criminal; j. 16/10/2020) sublinhei.

Portanto, com relação ao corréu Willian, a guarda das munições e o tráfico ficaram evidentes pela confissão, pela apreensão daquelas, pelas circunstâncias da abordagem, apetrechos (balança de precisão, facas e lâmina, com resquícios de droga), forma de embalagem dos entorpecentes encontrados, bem como devido aos

depoimentos seguros das duas testemunhas da acusação ouvidas na fase judicial.

Destarte, restou comprovado nos autos a prática, pelo réu Willian, do crime previsto no artigo 12, da Lei n. 10/826/03, e no artigo 33 "caput", da Lei 11.343/06, na modalidade guardar/ter em depósito, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Não há nos autos qualquer circunstância que exclua os crimes ou isente de pena o acusado. Inexiste elemento no qual se possa inferir que o réu Willian ao tempo da ação não tinha capacidade de entendimento e/ou autodeterminação com relação aos delitos que lhe é imputado.

No mais, tendo em vista que o réu foi preso em flagrante durante o período de calamidade pública (instituída pelo Decreto Legislativo n. 06/20 e pelo Decreto n. 64.879, do Estado de São Paulo), decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), de rigor o acolhimento do pleito do Ministério Público no sentido de reconhecer a incidência da agravante genérica de caráter objetivo, prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, não exigindo a lei que se comprove de que forma a pandemia facilitou a ocorrência do crime.

B) Com relação aos réus Gionathan e Fernanda:

Conforme reconhecido pelo próprio Ministério Público, a autoria do delito é duvidosa em relação à ré Fernanda. Outrossim, em relação ao réu Gionathan, não existem provas de que ele tenha praticado o delito denunciado.

O acusado Gionathan, na fase policial e em juízo, mencionou que no intuito de comprar um celular, encontrou com o corréu Willian, ocasião em que, diante do seu estado depressivo por um término de relacionamento, aceitou o convite daquele para "fumar um baseado e comer uma pizza" em sua residência, local em que acabou dormindo no dia dos fatos. Respondeu que foi surpreendido com todo o material e entorpecentes encontrados pelos policiais, tendo somente visualizado o cigarro de maconha e um pino de cocaína que iriam consumir, negando sobre os microtubos vazios apreendidos estarem sob o sofá; que desconhecia que o corréu Willian traficava drogas ilícitas; que a corré Fernanda estava dentro do quarto; nega sobre qualquer envolvimento nos roubos investigados (fls. 08 e 443/453 - mídia: 1h11min).

Das testemunhas de defesa arrolada pelo mesmo (Gionathan), a Sra. Elenira Angêlica Mauro Aner, sua genitora, relatou sobre o filho ter comunicado que iria comprar um novo celular no Jardim Maria Luiza, haja visto que o que possuía havia sido danificado pela ex-namorada; disse que ele nunca teve envolvimento com tráfico de drogas, tampouco com a polícia. Acrescentou sobre conhecer a corré Fernanda, em razão da família ter residido há anos no mesmo bairro; que há tempos o filho não se encontrava com o corréu William; que desconhece sobre qualquer comentário sobre envolvimento criminoso da corré Fernanda (fls. 443/453 - mídia: 32min). No mesmo sentido foi o teor do depoimento do Sr. Pedro Martinho Mauro Sachs, irmão do corréu Gionathan, que afirmou sobre a inexistência de envolvimento do mesmo em práticas criminosas (fls. 443/453 - mídia: 39min).

A corré Fernanda, em interrogatório judicial, confirmou que os policiais adentraram em sua residência, e apreenderam os materiais, entorpecentes e munições mencionados, os quais pertencem exclusivamente ao filho, ora corréu Willian. Indagada, informou que no local residem apenas ela e o filho, e que apesar de ter conhecimento e desaprovado sobre a traficância praticada pelo mesmo, negou possuir qualquer envolvimento, afirmando sobre o temor que possui em relação à agressividade do filho. Questionada, disse que presta serviços de faxina três vezes por semana e que não cozinhava na residência, de forma que realizava suas refeições na casa de sua sobrinha, onde passava a maior parte do tempo para evitar de brigar com o filho. Acrescentou conhecer o corréu Gionathan, afirmando que ele havia pernoitado em sua residência no dia dos fatos (fls. 443/453 - mídia: 59min e 1h20min, em continuidade).

Das testemunhas arroladas pela corré Fernanda, o Sr. Sidnei Camilo, amigo longínquo daquela e proprietário da loja localizada defronte à casa da mesma, reforçou sobre a inexistência de qualquer envolvimento da corré em práticas delituosas, posto ser uma pessoa boa, prestativa e honesta; que tinha conhecimento acerca da "movimentação estranha" na casa da corré, em razão de conduta exclusiva de seu filho Willian com venda de drogas, da qual a genitora desaprovava e se

ausentava do lar para “não ver as coisas erradas”. Indagado, disse não conhecer o corréu Gionathan (fls. 443/453 – mídia: 44min).

As demais testemunhas arroladas pela corré Fernanda, Sra. Grasiela Nayara (fls. 443/453 – mídia: 52min) e Maria Cunegundes Gomes (fls. 443/453 – mídia: 57min), declararam sobre não conhecer o corréu Gionathan; e sobre a anuência acerca do envolvimento com drogas do filho Willian, acrescentando aquela sobre a agressividade do mesmo em desfavor de sua genitora..

Ainda, colhe-se do relatório investigativo, que da análise do celular da corré Fernanda apreendido, “nada de relevante para a investigação fora encontrado” (fl. 312).

Quanto ao acusado Gionathan, infere-se do conjunto probatório que ele não residia no local, estando presente casualmente no momento dos fatos para fins de consumo próprio de entorpecentes, destacando-se que o corréu Willian admitiu a propriedade de todo o produto do crime apreendido, inclusive das munições.

Como se vê a prova não é segura. Embora a corré Fernanda tivesse conhecimento sobre o envolvimento do seu filho Willian no cometimento dos crimes descritos na denúncia, não há indícios da participação dos demais acusados no comércio em conjunto dos entorpecentes. Para a responsabilização dos acusados, a prova produzida nos autos da presente ação penal deveria indicar, além de sua(s) participação(s), ao menos a intenção em comum de se beneficiar do produto do crime, não se desconhecendo acerca da ausência de pretérita informação de eventual envolvimento de tráfico em relação aos acusados Fernanda e Gionathan. Ou seja, malgrado comprovado nos autos que os entorpecentes eram armazenados na residência comum do corréu Willian e da corré Fernanda, não se revela plausível que esta, assim como o corréu Gionathan presente no local, tenham sido os coautores da traficância e guarda das munições apuradas, sendo que o próprio corréu Willian os isenta sobre o conhecimento das mesmas.

Diante da prova dos autos, não restou apurado de forma suficiente o envolvimento dos acusados Gionathan e Fernanda nos delitos descritos na denúncia. Logo, a prova produzida sob o crivo do contraditório, não autoriza o decreto condenatório com relação aos mesmos. Desta feita, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que, no processo criminal, o decreto condenatório exige certeza absoluta, não bastando eventual probabilidade de serem esses acusados os autores dos fatos criminosos. Em razão disso, já se decidiu:

“A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível criminoso é condenar um possível inocente” (TJSP – AC 142.227-3 – Rel. Nelson Fonseca – JTJ 170/315)

Vale ressaltar que vigora no Processo Penal o princípio do “in dubio pro reo” a informar a absolvição por insuficiência de provas. Confira-se:

“Aplicação do princípio in dubio pro reo. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para a condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, “a prova para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática” (RJTJERGS 177/136)

Vê-se, pois, que a dúvida sempre beneficia o acusado, uma vez que a condenação exige certeza e o Direito Penal não opera em conjecturas. Sem a certeza cabal da autoria e da culpabilidade não pode o magistrado proferir condenação.

Destarte, os réus Fernanda e Gionathan não podem ser responsabilizados criminalmente.

Por consequência, não ficou comprovada a prática do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06. A característica da associação é justamente a estabilidade do vínculo que une os agentes. Logo, por mais que o art. 35 da lei de drogas faça uso da expressão “reiteradamente ou não”, a tipificação desse crime depende da efetiva estabilidade ou permanência, avaliadas caso a caso, pois tais características é que diferenciam o crime de associação para fins de tráfico de um eventual concurso de agentes do art. 29 do Código Penal.

Nesse contexto, como já pronunciou o C. Superior Tribunal de Justiça, a caracterização do crime de associação para o tráfico depende do dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo a reunião ocasional de duas ou mais pessoas

incapaz de provocar a inserção ao tipo do art. 35 da Lei 11.343/06 (HC 254.428/SP). E, no caso em apreço, além da absolvição ora reconhecida, não há prova objetiva do animus associativo, uma vez que a estabilidade e permanência da associação criminosa entre os réus não restou demonstrada. O mesmo valor dos depoimentos policiais para a caracterização do crime de tráfico há que ser adotado quanto à inexistência de prova da permanência e estabilidade dos acusados em uma associação para o tráfico e guarda de munições, dos quais sequer participaram. A propósito, confira-se a interpretação analógica com referência a dispositivo similar da antiga Lei de Tóxicos:

“Para caracterizar o crime do art. 14 a associação deve ser estável” (STF – HC 76.247 – Rel. Nelson Jobim – j. 16.06.1998 – RTJ 170/291)

“O delito de associação para o tráfico, previsto no artigo 14 da Lei 6.368/76, não pode, de forma alguma, ser comparado a um mero concurso de agentes, sendo necessária para a sua caracterização a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de associar seja separada da vontade à prática do crime visado” (TJSP – Ap. 295.901-3/1-00 – Rel. Barbosa Pereira – j.06.04.2000 – RT 779/571)

Para o texto atual, veja-se o precedente:

“[...] 1. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006. Doutrina. Precedentes.[...]” (Superior Tribunal de Justiça, RHC 108.003/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, j. 07/05/2019)

Conclui-se, pois que, diante da comprovação da materialidade e autoria para o crime de tráfico e guarda irregular de munições somente ao acusado Willian, a condenação é medida de rigor, incidindo, ainda, a aludida agravante pandêmica.

Passo a dosar a pena a ser imposta ao réu Willian:

Ao delito descrito pelo artigo 33 “caput”, da Lei 11.343/06 são cominadas as penas de reclusão e multa; e ao delito descrito no artigo 12, da Lei n. 10/826/03, são cominadas as penas de detenção e multa.

Consideradas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, tendo em vista seus maus antecedentes (fls. 61/68 e 79/82), fixo a pena base 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, com fulcro também no artigo 42, da Lei n. 11.343/06, em face da quantidade e natureza diversificada dos entorpecentes apreendidos, o que revela maior culpabilidade de sua conduta, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa (para o crime previsto no artigo 33 “caput”, da Lei 11.343/06), cujo valor fixo no mínimo legal, em virtude da situação financeira do acusado; e em 01 (hum) ano, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção, e 12 (doze) dias-multa (para o crime previsto no artigo 12, da Lei n. 10/826/03), também no valor unitário mínimo.

Na segunda fase de aplicação da pena, deixo de considerar a reincidência do réu para evitar o “bis in idem”, uma vez que suas condenações anteriores já foram consideradas como maus antecedentes na primeira fase. Ainda, a confissão espontânea do réu irá se compensar com a agravante dos delitos terem sido cometidos em ocasião de calamidade pública (artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal), mantendo-se as penas inalteradas. Não há outras circunstâncias agravantes ou atenuantes.

De outro lado, na terceira fase, registra-se que não foram preenchidos os requisitos exigidos pelo § 4.º do art. 33, da Lei n. 11.343/06. Denota-se que, além da ausência de primariedade do réu, de acordo com os depoimentos dos policiais, o mesmo era conhecido por eles no meio delitivo..

Desse modo, torno as penas definitivas por inexistirem outras circunstâncias modificadoras.

Diante do concurso material, previsto no artigo 69 do Código Penal, as penas devem ser somadas se de mesma natureza. Entretanto o crime de guarda de munições possui pena distinta (detenção) do delito de tráfico (reclusão), havendo que se aplicar primeiro a reclusão e, após, a detenção, por analogia ao disposto na parte final do artigo 69, do CP.

Deixo de apreciar a detração para fins de estabelecimento do regime inicial, na forma do § 2.º do artigo 387, do CPP requerido pela defesa, tendo em vista que a

progressão exige, além do cumprimento da pena, outros requisitos subjetivos que devem ser analisados pelo Juízo da Execução. Também no Juízo da Execução é que se poderá analisar eventuais outras penas impostas e o comportamento carcerário do réu. Nesse sentido:

“ [...] APLICAÇÃO DO ART. 387, § 2.º, DO CPP – Impossibilidade – Detração é matéria afeita ao juízo da execução, o qual possui maiores informações acerca do efetivo tempo que o sentenciado permaneceu recluso e outras eventuais penas impostas [...]” (HC2159904-03.2015.8.26.0000, 15.09.2015)

Dessa forma, considerando a reincidência e a gravidade dos crimes praticados, especialmente de traficância, além do fato desse tipo penal necessitar de uma resposta social mais efetiva em relação à criminalidade, principalmente considerando o crescente aumento no uso de entorpecentes pelo País, o réu iniciará o cumprimento da pena no regime fechado, não fazendo jus nem à substituição nem à suspensão condicional da pena (na forma dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, bem como por força do que dispõe o artigo 2.º, § 1.º, da Lei n. 8.072/90, na redação dada pela Lei n. 11.464/07). Aos crimes hediondos e assemelhados não se aplicam os benefícios da Lei n. 9.714/98, de caráter genérico. O cumprimento da pena, na espécie, é regulado pela Lei n. 8.072/90, especial e não revogada pela Lei n. 9.714/98.

Por fim, o réu não terá o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que permaneceu preso durante toda a tramitação do processo e também porque, até a prolação da presente sentença, a situação fática não se alterou, estando ainda presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar. A custódia preventiva, para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos delitos cometidos, e para assegurar a aplicação da lei penal, é necessária para acautelar o meio social ante a concreta possibilidade de reiteração criminosa, diante dos maus antecedentes e reincidência do réu, e as evidências de que, em liberdade, o agente empreenderá esforços para escapar da aplicação da lei penal. Nesse sentido: HC nº 109.723, Primeira Turma, Relator Ministro Luis Fux, DJe de 27.06.2012.

Por derradeiro, não há indenização a ser arbitrada nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, até porque não há pedido formal a respeito.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e, em consequência, condeno WILLIAN ANSELMO PEREIRA, à pena de 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 01 (UM) ANO, 02 (DOIS) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE DETENÇÃO, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 612 (SEISCENTOS E DOZE) DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo, considerando-se sua condição financeira, com os reajustes legais, por incursos nas penas dos artigos 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06 e artigo 12, da Lei n. 10.826/03, ambos cumulados com artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal e na forma do artigo 69 do Código Penal.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.

Autorizo a incineração do material entorpecente apreendido. Oficie-se à Delegacia de Polícia para incineração dos entorpecentes, caso ainda não realizada.

Deixo de condenar o réu Willian no pagamento das custas processuais, vez que ele é beneficiário da assistência judiciária gratuita (fls. 375/376).

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu Willian no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

ABSOLVO os réus WILLIAN ANSELMO PEREIRA e GIONATHAN EDUARDO MAURO SACHS da imputação que lhes foram feitas como incursos no artigo 35, da Lei n. 11.343/06, com fulcro no art. 386, V (Gionathan) e VII (Gionathan e Willian), do Código de Processo Penal.

ABSOLVO a ré FERNANDA GISELDA BATISTA ANSELMO da imputação que lhe foi feita como incurso nos artigos 33, §1º, inciso III, e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, com fulcro no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal.

Expeçam-se, em razão da sentença, alvarás de soltura clausulados em favor dos réus GIONATHAN EDUARDO MAURO SACHS e FERNANDA GISELDA BATISTA ANSELMO, com urgência.

Ciência ao M.P.

P.I.C.

Araraquara, 10 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA